

1511118-18.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... os policiais confessado informalmente o tráfico de drogas.

São estas as provas que, a meu ver, não autorizam a condenação pelo grave crime de tráfico.

Não se está afirmando pela inexistência de indícios em desprol do réu, mas somente que, por demais, frágeis e inaptos a fundamentar grave condenação criminal.

De fato, entendo que do simples fato de estar em local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511118-18.2019.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511118-18.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face do acusado PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS, já qualificado, dado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.44.

Defesa preliminar juntada às fls.51.

Recebimento da denúncia às fls.53/54.

Citação às fls.73.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu, interrogado, as partes debateram e foi prolatada sentença, cuja liberação foi prevista para o dia

26/08/2022 (fls.74/78).

Ministério Público, em debates orais, pediu a condenação nos moldes da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É o relatório.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão estatal.

De fato, a prova trazida para os autos não autoriza a imposição do oneroso decreto condenatório tal qual pretendida pelo órgão ministerial.

A materialidade delitiva é indubitosa, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de exibição e apreensão (fls.08) e laudo pericial de fls.14/16 (apenas 5,9 grama de cocaína).

De outro canto, exsurtem dúvidas acerca da autoria delitiva. Vejamos:

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva, afirmando, de maneira idêntica ao que havia dito na fase de investigação (fls.12), ter sido abordado sem drogas, portando apenas 55 reais. Negou relação coma droga apreendida.

Em contrapartida, os agentes estatais relataram, em juízo, que em patrulhamento de rotina avistaram o acusado, a distância de cerca de 30 metros, mexendo em monte de folhas num terreno baldio. O réu, ao notar que seria abordado, jogou dois "pinos" de cocaína que trazia consigo. Em revista pessoal, lograram apreender 55 reais em posse do denunciado. Ato contínuo, foram ao monte de folhas do terreno acima citado e encontraram mais 31 "pinos" da mesma droga e 80 reais. Indagado, o réu teria, segundo, os policiais confessado informalmente o tráfico de drogas.

São estas as provas que, a meu ver, não autorizam a condenação pelo grave crime de tráfico.

Não se está afirmando pela inexistência de indícios em desprol do réu, mas somente que, por demais, frágeis e inaptos a fundamentar grave condenação criminal.

De fato, entendo que do simples fato de estar em local conhecido pela prática de tráfico, aliado à quantidade inexpressiva de drogas (apenas 5,9 gramas - se considerado o total de entorpecentes apreendidos) e dinheiro, não é possível afirmar com absoluta certeza que o réu seja traficante.

Efetivamente, ser abordado em local conhecido por venda de drogas não é suficiente para se chegar à conclusão de que seja o réu traficante.

Nesse diapasão, exemplar o acórdão a seguir transcrito parcialmente em feito desta Comarca de Araras, "ex vi":

"(...) Acerca do indício de ter sido o acusado preso em conhecido ponto de tráfico, o argumento, com o maior respeito, não faz sentido. Se um indivíduo com um pacote de açúcar União fosse visto na porta de um supermercado, isto aumentaria as "evidências" de que ia vendê-lo? Claro que não; afinal, quem compra algo compra-o onde costuma ser vendido. (...) A eventual concentração de pessoas em um mesmo local pode indicar tanto a traficância quanto o uso comum (aliás, o usuário de

crack raramente é visto sozinho; pelo contrário, está sempre em grandes aglomerações)." (TJSP, 10ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 1500094-40.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Francisco Bruno, em 1º. de julho e 2021)

Portanto, não há nos autos, data vênia, prova robusta que indique que a substância apreendida com o denunciado (apenas dois pinos, já que o restante estava em local diverso com parcos indícios de que eram do réu) se destinava ao tráfico, pelo que a desclassificação do delito, como requer a defesa, é medida que se impõe.

Assim sendo, apesar de todo crédito que merecem os depoimentos policiais, é certo que, no caso dos autos, mostraram-se frágeis, sem a necessária consistência a sustentar condenação pela mercancia ilícita.

Além disso, no caso concreto, apesar de, se adotada a tese ministerial, o denunciado ter sido detido em situação flagrancial, nem mesmo a autoridade policial, acostumada com situações desta estirpe e talvez desconfiando da ausência de sérios indícios, optou (como se opção fosse) em lavrar o respectivo auto prisional, o que é, deveras, sintomático da precariedade probatória.

Não bastasse o já fundamentado, causa a estranheza a afirmação dos policiais no sentido de que o réu teria confessado informalmente, eis que, logo depois, quando interrogado na fase investigativa, negou.

Em que pese a validade dos depoimentos dos agentes estatais, não podem ser tido como absolutos e incontestáveis. Ao revés, como toda prova, deve encontrar respaldo nos demais elementos dos autos e também não podem afrontar o senso comum ou as chamadas máximas de experiência.

Assim sendo, da mesma forma que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito" (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472), não deve, por si só, a condição de servidor estatal ser tida como prova incontestável de veracidade de seu conteúdo, sendo imperiosa a análise probatória conglobante, bem como que não agrida as máximas de experiência.

Isso porque, no Brasil, nenhuma prova tem valor absoluto e pré-fixado em lei, não se adotando, ao menos em matéria criminal, o sistema da prova tarifada.

Sobre o tema:

"No Brasil, acolheu-se o terceiro princípio, que é intermediário entre os dois primeiros: o da persuasão racional do juiz, também denominado livre convencimento motivado (...) o juiz apreciará livremente a prova, observando o que consta dos autos, mas ao proferir a sentença, deve indicar os motivos que lhe formaram o convencimento. Não há uma hierarquia das provas. O juiz deve ler os autos, analisar os elementos colhidos e formar livremente o seu convencimento. Porém, este deve fundamentar-se naquilo que esteja nos autos e ser exposto na sentença" (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral e processo de conhecimento (1ª parte); 12ª. edição. São Paulo: Saraiva, 2015;. p. 109)

Assim, todas devem ser sopesadas à luz do princípio da persuasão racional, cotejando-as com os demais elementos concretos existentes nos autos, não sendo admissível ainda que ofenda as chamadas máximas de experiência, de forma que testemunhos que atentem ao que ordinariamente acontece não devem ser considerados aptos a fundamentar eventual condenação.

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, ao processo penal, em capítulo destinado às provas, prevê em seu artigo 375 que:

“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”

Em sentido parecido o art. 852-D, da CLT, também autoriza o uso de regras de experiência, de forma que seu significado não é estranho ao mundo jurídico.

Almejando esclarecer o significado de tal conceito trago à baila decisão proferida pela Corte Suprema do Peru, “in verbis”:

"A máxima da experiência nos diz que um determinado fato, atitude ou fenômeno pode se manifestar de uma certa maneira devido à observação constante e repetida de eventos comuns devido à repetição uniforme de certos eventos da ação humana". <https://lpderecho.pe/valoracion-prueba-penal-maximas-de-la-experiencia/>

E, assim sendo, “contribuem para a formação do convencimento do Juiz através de princípios práticos da vida e da experiência daquilo que geralmente acontece” (Napoleão Nunes Maia Filho, Juiz do TRF-5, citando o Professor João Carlos Pestana Aguiar, em “Comentários ao CPC”, vol. IV, RT, São Paulo, 1977, p.103)

E mais:

“O juiz, como homem culto e vivendo em sociedade, no encaminhar as provas, no avalia-las, no interpretar e aplicar o direito, no decidir, enfim, necessariamente usa de uma porção de noções extrajudiciais, fruto de sua cultura, colhida de seus conhecimentos sociais, científicos, artísticos ou práticos, dos mais aperfeiçoados aos mais rudimentares. São as noções a que se costumou, por iniciativa do processualista STEIN, denominar máximas da experiência, ou de regras da experiência, isto é, juízos formados na observação do que comumente acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por qualquer pessoa de cultura média” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º. Volume, 7ª. Edição. Editora Saraiva, 1982; p. 337)

Desta forma, tentando ser conciso, nem sempre o testemunho dos agentes estatais deve ser considerado meio idôneo de prova, eis que, quando contrariar os demais elementos dos autos ou as regras de experiência, caberá ao Estado demonstrar, por outros elementos, sua veracidade.

Imaginar-se o contrário importaria dar crédito a afirmações desconectadas da realidade vivida.

Indago. Soa mesmo verossímil que o réu tenha admitido informalmente a prática delitativa aos policiais militares para, logo em seguida, quando ouvido perante a autoridade policial, negar? A mim, não parece nada comum.

Ademais, ainda que ingenuamente se possa admitir tal possibilidade, a confissão informal não é meio de prova, eis que necessita de confirmação judicial. Nesse sentido:

“Há, por fim, a famigerada “confissão informal” feita aos agentes da lei, no momento da prisão, a meu ver sempre suspeita (afinal, nossos criminosos, não raro bastante perigosos, são de uma quase santa sinceridade no momento da prisão...) e incabíveis como prova (embora, reconheço, meu entendimento seja isolado na Câmara). Essa autoincriminação, neste caso não pode ser aceita: ela não é compatível com fatos comprovados acima de dúvida razoável”. (TJSP, 10ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 1500094-40.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria

do Des. Francisco Bruno, em 1º. de julho e 2021)

Vamos além. Nem mesmo, no caso em apreço, se adotada como totalmente verídica a versão dos incansáveis policiais, entendo ser possível a condenação por tráfico.

Isso porque, conforme disseram, o réu foi visto mexendo em monte de folhas, ao ver a viatura jogou duas porções, sendo com ele apreendido 55 reais, e no referido monte outras porções da mesma droga e dinheiro.

Não houve investigação. Não houve campana. Não foi flagrada venda, trocas suspeitas ou movimento anormal de pessoas, como de costume ocorre em pontos de tráfico. Não havia delação apontando o réu como traficante. Em suma, não havia nada.

Desta feita, qual prova seria capaz de nos levar a concluir com a certeza necessária para a condenação criminal pretendida, de que o réu não estaria ali, naquele monte de folhas, escondendo drogas para seu consumo ?

A quantidade de drogas (singelos 5,9 gramas de cocaína) seria um parâmetro seguro no caso em apreço ?

Entendo que não. Explico trazendo à baila decisão do Egrégio Tribunal Paulista em mencionados estudos realizados por entidades que gozam de enorme prestígio da comunidade científica nacional. Vejamos:

“(...) a triste realidade, conhecida de todos, é que 2,0g de crack são consumidos por um usuário em horas, quicâ minutos. Mas, se se deseja algo de mais “científico”, um estudo realizado pela FIOCRUZ, em parceria com o Ministério da Saúde, apontou que “os usuários de crack e/ou similares referem consumir, num dia 'normal' (padrão) de uso, 13,42 pedras/porções destas drogas (IC95%: 11,97-14,88). Obviamente, não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e conteúdo do que cada usuário denomina pedra”. (BASTOS, Francisco Inácio et al org. Pesquisa nacional sobre o uso de crack. Rio de Janeiro: Editora ICICT/FIOCRUZ, 2014, p, 62 - <https://bit.ly/2x7le6G> 2 SILVEIRA, Dartiu X da et al. Fatores associados a perfusão cerebral anormal em dependentes de cocaína. Rev. Bras. Psiquiatr. [online]. 2001, vol. 23, n.º 1, pp. 9/14 <https://doi.org/10.1590/S1516-44462001000100004>). (...) Este estudo confirma outro anterior, realizado por profissionais da Escola Paulista de Medicina Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), num período de onze a cento e vinte meses, que concluiu que “[a] quantidade de 'crack' consumida nesses períodos variou de 1 a 15 gramas por dia, sendo a mediana 3g” (...)” (TJSP, 10ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 1500094-40.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Francisco Bruno, em 1º. de julho e 2021)

Assim sendo, adotados os parâmetros acima mencionados, concluímos que, mesmo se consideradas as drogas escondidas no monte de folhas, a quantidade apreendida seria facilmente consumida por usuário em menos de dois dias. Logo, é insuficiente para caracterizar, ainda que aliada à inverossímil confissão informal, a destinação ao tráfico de drogas.

Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, pois não trazidos aos autos elementos outros, tais como potenciais compradores, grande quantidade de droga, dinheiro trocado, várias pessoas envolvidas etc, que indicassem o comércio ilícito.

Simples conjecturas mostram-se demasiado frágeis para a condenação, que, efetivada, o seria em franca violação ao princípio da presunção de inocência.

Em absoluto, não ficou demonstrada a vinculação do réu ao comércio ilícito, não presenciando, os policiais, transação e movimentação, no local, típicas do

exercício da funesta atividade.

O ônus da prova incumbe ao representante do Parquet, que tem as melhores condições de provar as hipóteses que formula; o acusado é sempre a parte mais fraca ante o Estado e sua estrutura.

Ao Estado cabe afastar a presunção de inocência, não interessando já que tutela por meio do seu sistema processual penal a liberdade a condenação de um possível inocente, mesmo diante do risco de absolver um culpado.

Nesse sentido: "O farol que deve orientar o Juiz na decisão da causa são as provas dos autos. Se elas não indicam com segurança a culpa do réu, será força pronunciar o non liquet e absolvê-lo. Mais que meras conjecturas acerca da culpabilidade do acusado, são necessárias, para sua condenação, provas tão claras como a luz meridiana: probationes luce meridiana clariores (...)." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº. . 00385778.3/0-0000-000, da Comarca de São Paulo, de relatoria do Des. Carlos Biasotti. São Paulo, 20 de dezembro de 2007).

A dúvida impõe a absolvição em relação ao crime de tráfico.

Possível, e de rigor, a condenação pelo crime subsidiário, qual seja, o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Isso porque, adotadas como válidas as palavras dos agentes policiais na parte em que corroboradas pelos demais elementos dos autos (consta dos autos prova documental de que drogas foram realmente apreendidas - fls.08 e 14/16), tem-se que o réu, no mínimo, flagrado em posse de dois "pinos" de cocaína.

Uma vez não comprovada a destinação ao tráfico, deve ser o réu condenado por porte para consumo pessoal.

Importante aqui mencionar que não é o caso de se determinar a remessa ao Jecrim. Ressalvado meu entendimento pessoal pela competência absoluta do JECRIM, o E. TJSP em conflitos de competência tem decidido da seguinte forma: "Denúncia oferecida pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) - Réu acusado de, em tese, trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização - Denúncia recebida e processo instruído perante a Vara Criminal da Comarca Decisão que acolhe pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e determina de remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis - Precedentes desta Colenda Câmara Especial." (TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0004958-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande).

Ante todo o exposto e considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para desclassificar a conduta imputada ao acusado para a prevista no artigo 28, §1º, da Lei nº 11.343/06, impondo a PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS, já qualificado, que é primário (fls.60/61), a pena de ADVERTÊNCIA, nos termos do inciso I, do artigo acima mencionado, a ser aplicada após o trânsito em julgado.

Providencie-se as comunicações necessárias. Anotem-se. Expeça-se certidão ao defensor nomeado.

Isento de custas, pois condenado por crime de pequeno potencial ofensivo.

Abra-se vista ao MP para ciência e interposição recursal (já manifestado interesse em audiência). Publique-se e intime-se a Defesa.

PRI.

Araras, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA